

1501320-68.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Pindamonhangaba

Foro: Foro de Pindamonhangaba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... da imputação de associação para o tráfico. Ressalta-se, neste ponto, que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, opinou pela improcedência da pretensão punitiva pelo delito de associação para o tráfico. Passo a analisar a imputação do delito de tráfico de drogas. O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pindamonhangaba

Foro de Pindamonhangaba

Vara Criminal

Rua Alcides Ramos Nogueira, 780, Real Ville, Pindamonhangaba - SP - cep 12421-010

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1501320-68.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2262174/2021 - 01º D.P.

PINDAMONHANGABA, 20471345 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA, 1468/21/412 - 01º D.P.

PINDAMONHANGABA, 2262174 - 01º D.P. PINDAMONHANGABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO PERI DE LINDE e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA e outro

Data da Audiência:

27/04/2022

Réu Preso

Aos 27/04/2022, nesta Comarca de Pindamonhangaba, do Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum local, na sala de audiências da Vara Criminal, onde presente se achava o MM. Juiz Substituto, DR. LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA, o representante do Ministério Público, Dr. CARLOS EDUARDO DE CASTRO PACIELLO, o(s) (a)(s) réu(s)(ré)(s) FABIO PERI DE LINDE e LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO, acompanhado(s)(a)(s) do(s)(a)(s) defensor(es)(a)(s) Dr(s). (a)(s) Amanda Stella da Silva Antunes, bem como da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e pela defesa, Daniel Trevisan da Silva e Fabrício Antunes Trindade. Nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, que versa sobre a realização das audiências virtuais, em razão da suspensão do expediente forense decorrente da pandemia de Coronavírus verificada no país, a presente audiência será realizada virtualmente, através da ferramenta Microsoft Teams, sendo que todos os depoimentos serão gravados e posteriormente direcionados em pasta própria via One Drive, cujo link será disponibilizado no final do termo de audiência. Antes do interrogatório, foi dada a oportunidade para que a defensora conversasse com seus clientes. A seguir foram ouvidas as testemunhas e foram ouvidos os réus, tendo as

inquirições sido realizadas por meio de gravação audiovisual, nos termos do artigo 405, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.719/08. Após, pelo MM. Juiz foi deliberado: Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal. Declaro encerrada a instrução, abrindo prazo para apresentação de alegações orais finais. Pelo Promotor de Justiça foram apresentadas alegações, nos termos do artigo 411, § 4º do Código de Processo Penal, por meio de gravação audiovisual. Durante sua fala, foi sustentada a procedência parcial da ação, com a absolvição dos réus em relação ao delito de associação para o tráfico, e a desclassificação do delito de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei 11.343/06 em relação ao acusado Fábio, manifestando-se, também, a respeito da dosimetria de pena, tudo conforme registro audiovisual. Pela Defensora foram apresentadas alegações, nos termos do artigo 411, § 4º e seguintes do Código de Processo Penal, por meio de gravação audiovisual. Durante sua fala, foi sustentada a improcedência da ação, manifestando-se subsidiariamente, a respeito da aplicação da pena, conforme registro audiovisual. Pelo MM. Juiz foi proferida oralmente a sentença, de forma resumida, sendo que a íntegra da decisão segue no presente termo de audiência. Pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: FABIO PERI DE LINDE e LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO estão sendo processados pelos supostos delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico ocorridos em 24/09/2021. Realizada audiência de custódia às fls. 71/75. Apresentada defesa. A denúncia foi regularmente recebida. Na presente audiência foi colhida prova oral, conforme constou acima e interrogados os réus. Alegações orais resumidas acima e registradas em gravação audiovisual, conforme opção manifestada pelo Promotor de Justiça e Defensora. Sentença proferida oralmente de forma resumida durante as gravações da audiência, com a íntegra conforme segue. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Inicialmente, a imputação de associação para o tráfico, em relação a ambos os acusados, não merece prosperar. Isso porque, para que se verifique a tipicidade do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é necessária a demonstração de algum grau de estabilidade e permanência na associação dos agentes. Nesse sentido, a lição da doutrina: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão 'reiteradamente ou não', a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29) [...] Se se trata de crime contra a paz pública, há de se entender que apenas a associação estável e permanente é capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado. Logo, uma associação instável e efêmera, características inerentes ao concurso eventual de agentes, não tipifica, de per si, o crime do art. 35 da Lei 11.343/06" (LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único. 7 ed. Salvador: JusPODIVM, 2019, p. 1219/1220). Na hipótese em deslinde, contudo, o Ministério Público não logrou êxito em comprovar, por elementos objetivos concretos, qualquer nível de apuração no vínculo existente entre os réus na associação para fins de tráfico. Evidenciou-se tão somente que eles estavam em conluio, na abordagem específica ocorrida no dia 20 de junho de 2019, o que não significa que essa associação tenha estabilidade e permanência suficientes a afastar o mero concurso eventual de agentes. A propósito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO. PLURALIDADE DE AGENTES. INEXISTÊNCIA. LOCALIDADE DOMINADA POR FACÇÃO CRIMINOSA. PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NO GRUPO CRIMINOSO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ASSOCIAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. [...]. 1. Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável, para a configuração do crime de associação para o tráfico, a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos. 2. Ainda que seja de conhecimento o domínio da localidade por facção criminosa e a posse de arma e munição de uso restrito denotem envolvimento com atividades criminosas, não há na denúncia, na sentença ou no

acórdão qualquer apontamento de fato concreto a caracterizar o vínculo de agentes, requisito necessário para a configuração do delito de associação para o tráfico, não tendo sido sequer indicado quem seriam os outros que com ele estariam associados, de modo que, ausente o requisito atinente à pluralidade de agentes, imperiosa é a absolvição. 3[...] (STJ - HC: 474965 RJ 2018/0275958-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2019). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 35 DA LEI N. 11.343/2005. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imprescindível a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa (HC n. 270.837/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015). 2. Ordem concedida para absolver o paciente da prática do delito do art. 35 da Lei n. 11.343/06. (STJ - HC: 393231 RJ 2017/0064014-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 21/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2017). [...]. Associação para o tráfico de drogas. Estabilidade e permanência da associação não demonstradas. Provas insuficientes. Absolvição mantida. [...]. (TJ-SP - APL: 00022480320128260362 SP 0002248-03.2012.8.26.0362, Relator: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 05/12/2016, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2016). O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de drogas, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória. Por outro lado, imperiosa a absolvição dos acusados da imputação de associação para o tráfico. Ressalta-se, neste ponto, que o próprio Ministério Público, titular da ação penal, opinou pela improcedência da pretensão punitiva pelo delito de associação para o tráfico. Passo a analisar a imputação do delito de tráfico de drogas. O tipo objetivo do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objeto material é a droga, o jurídico é a saúde pública. A materialidade do delito acha-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), de constatação prévia (fls. 23), exame químico-toxicológico (fls. 234/236), bem como pela prova oral produzidas sob o crivo do contraditório. No que tange à destinação das drogas, em relação ao acusado FÁBIO PERI DE LINDE, contudo, o Ministério Público não logrou êxito em comprovar a imputação contida na denúncia. Isso porque o réu foi surpreendido na posse direta de pequena quantidade de entorpecentes (02 pedras de crack), afirmou que é usuário de drogas e que estas se destinavam ao seu consumo pessoal. Além disso, apesar dos indícios trazidos pelos depoimentos dos policiais, não há prova suficiente de que o réu FÁBIO efetivamente tenha participado ou praticado qualquer núcleo do art. 33 da Lei de Drogas. O réu, em seu interrogatório, afirmou que portava as drogas que foram encontradas consigo para consumo pessoal e que os entorpecentes encontrados com o corréu LUCAS não lhe pertenciam. Nesse cenário, das provas colhidas sob o crivo do contraditório, não se extrai com a segurança necessária a existência de provas bastantes de que o réu efetivamente tenha praticado o crime de tráfico de drogas. Assim, inexistindo outros elementos seguros de prova capazes de demonstrar a eventual finalidade comercial da droga, a melhor solução é a desclassificação para o delito previsto

no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, como salientado pela representante do Ministério Público e pela Defesa. Com o advento da Lei nº 11.343/2006, não mais cabível a aplicação de pena privativa de liberdade aos acusados condenados pelo crime de porte de substância entorpecente. Com efeito, sendo o réu primário, entendendo que é suficiente a pena de advertência, não sendo proporcional a fixação de medida mais gravosa, a exemplo da prestação de serviços à comunidade. Por outro lado, em relação ao corréu LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO, há provas suficientes para a condenação pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas, afastada a causa de aumento atribuída na denúncia, uma vez que não suficientemente comprovado que o fato foi

praticado nas imediações de estabelecimento de ensino. Isso porque a versão trazida pelos policiais foi firme, coesa, mantendo-se íntegra desde a fase policial, além de ser corroborada com os elementos materiais apresentados (auto de apreensão e exame químico-toxicológico). Impõe-se ressaltar, nesta oportunidade, que o policial não está impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado. Neste sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal que: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p. 39.846). Além disso, o acusado foi surpreendido com quantidade relevante de drogas e o próprio réu LUCAS confessou em juízo que apenas parte das drogas que estavam em sua posse se destinavam ao seu consumo pessoal e que o restante das pedras de crack se destinavam ao consumo de terceiros, eis que estava guardando o entorpecente para uma terceira pessoa. Na espécie, observa-se que a forma de acondicionamento do tóxico, os relatos idôneos dos policiais e as demais circunstâncias fáticas não permitem a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06). Sob outro enfoque, não havendo comprovação de destinação exclusiva da droga ao uso próprio, pois nada impede que o usuário seja também traficante, inclusive para satisfazer o próprio vício, também se afigura inviável a desclassificação no caso concreto. O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória. Passo, portanto, à dosagem da pena. Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A definição de quais substâncias são consideradas ilícitas se encontra na Portaria SVS/MS n.º 344, de 12 de maio de 1998 (ver artigo 66 da Lei 11.343/06) e nesta definição se incluem todas as previstas no Anexo I (ver, p. ex., REsp.1.444.537/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016). Portanto, em referência ao critério da natureza da droga, por constarem da Lista F do Anexo I (substâncias de uso proscrito, ou seja, proibidas sob quaisquer circunstâncias ou concentrações pela natureza intrinsecamente nociva que possuem), merece valoração nesta fase a cocaína - e em maior grau o crack, seu derivado, por causar severa dependência em seus usuários. Por outro lado, em relação às circunstâncias judiciais previstas no Código Penal, a culpabilidade não ultrapassou a esfera de normalidade ao tipo penal; o réu é primário e os atos infracionais não podem ser utilizados como maus antecedentes (STJ - HC: 374624 SP 2016/0269323-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: DJ 21/08/2017); não há elementos seguros para valorar a conduta social do réu; tampouco a personalidade do agente, uma vez que demanda análise científica que escapa ao conhecimento técnico do Juiz; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo; e não há comportamento da vítima relevante para valorar. Com efeito, diante da natureza da droga, a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, existe a agravante da recidência. Presente, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, as quais devem ser compensadas, mantendo-se a pena no mesmo patamar. Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição. Ressalta-se que o réu é reincidente, o que afasta a possibilidade de aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas. Ante o exposto, torno definitiva a pena de 05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Considerando a reincidência e o quantum de pena, deve ser fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado. Em relação ao valor unitário da multa, a teor do art. 49, § 1º, do

Código Penal, entendo pela aplicação de 1/30 do salário mínimo, pois não há dados sobre a situação econômica do réu. Incabível a substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena, diante da reincidência e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada. Inalterados os pressupostos da prisão preventiva, em especial diante da reiteração criminosa e da confirmação da prática de fato criminoso de natureza grave, NÃO concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para: 1) absolver FÁBIO PERI DE LINDE e LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO do delito do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) condenar FÁBIO PERI DE LINDE à pena de advertência, por incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06, desclassificando-se a conduta anteriormente imputada quanto ao artigo 33 da Lei 11.343/06; e 3) condenar LUCAS JOSNEY DIAS CASTRO à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, por incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Expeça-se alvará de soltura clausulado em relação ao acusado Fábio. Recomende-se o réu Lucas, observando-se o regime fixado em sentença, servindo a presente como ofício de recomendação. Custas pelos réus, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs). Ressalto que o pagamento de custas processuais, no processo criminal, ocorre apenas nos casos de condenação do acusado, conforme se verifica da redação do artigo 4º, §9º, alínea "a" da referida Lei: "nas ações penais, em geral, o valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, será pago, ao final, pelo réu, se condenado". Em outras palavras, durante o processo, o acusado terá todo o necessário para sua defesa custeado pelo Estado, sem qualquer necessidade de pagamento para se defender, recorrer, produzir provas, ouvir testemunhas etc. O réu não ingressa nos autos por livre e espontânea vontade, e sim para que o Estado possa apurar sua participação em suposta conduta delituosa. Além disso, caso não tenha condições de constituir advogado, ser-lhe-á nomeado defensor dativo, às custas do Estado. Portanto, caberá ao acusado, em havendo trânsito em julgado da sentença condenatória, pagar as custas processuais, como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ressarcindo parcialmente e indiretamente o Estado, pelas despesas que causou, de forma que não há como se falar em Justiça Gratuita. Em havendo dinheiro apreendido, deverá ser utilizado, em um primeiro momento, para pagamento das custas processuais e, caso seja insuficiente, o acusado será intimado para complementação. Em contrapartida, após o pagamento das custas processuais, caso haja quantia remanescente, os valores perdidos serão destinados ao Fundo Nacional Antidrogas (artigo 63 da Lei 11.343/06). Sentença publicada em audiência. Certifiquem-se os atos praticados pelo(a) defensor(a) para fins de expedição de certidão de honorários. Saem os presentes intimados. Ficam as partes dispensadas de assinarem o presente termo. Pelo acusado Fábio e sua defensora foi manifestado interesse em NÃO RECORRER da sentença acima. Pelo MM. Juiz foi deliberado: "Considerando a manifestação do acusado, aguarde-se certificação do trânsito em julgado e expeça-se o necessário". No mais, aguarde-se eventual decurso de prazo para apresentação de recurso por parte do réu Lucas. Nada mais. Eu _____ (Maria Alessandra Tatiane de Almeida), Assistente Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

MM.JUIZ (assinatura digital)
DR.PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DEFENSOR:
RÉU:

- Link para a audiência: <https://bit.ly/3MuCff4>